

1504419-52.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cynthia Torres Cristofaro

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 23ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Réu:

GERSON DA SILVA SANTOS

Juíza de Direito: Dra. Cynthia Torres Cristófar

Vistos.

GERSON DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em combinação com o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

23ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1504419-52.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1504419-52.2021.8.26.0228 - 2021/000283

Autora:

Justiça Pública

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Réu:

GERSON DA SILVA SANTOS

Juíza de Direito: Dra. Cynthia Torres Cristófar

Vistos.

GERSON DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em combinação com o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque teria, no dia 17 de fevereiro de 2021, por volta das 11h50min, na Travessa Projetada, 63, São Rafael, nesta cidade e Comarca, durante a vigência de estado de calamidade pública decretado em decorrência da pandemia do Covid-19, trazido consigo, para entrega a consumo de terceiros, 33 porções com 83,4 gramas de maconha, 78 porções com 47,3 gramas de

cocaína e 86 porções com 13,7 gramas de crack, substâncias determinantes de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi preso em flagrante delito, tendo sido sua prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 54/57), concedida a liberdade provisória no curso do feito (fls. 78/79), revogada em sede recursal (fls. 128).

O acusado foi regularmente citado e notificado (fls. 92), e apresentou defesa preliminar por meio de defensor constituído (fls. 115/120), recebida a denúncia (fls. 125) e renovada a citação.

Durante a instrução, tomaram-se os depoimentos de três testemunhas, tendo sido o réu interrogado.

Manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público a condenação do acusado, nos termos da denúncia; pleiteou a defesa a absolvição, por falta de provas, pretendendo subsidiariamente a desclassificação ao delito do artigo 28 da Lei 11.343/2006 ou a fixação de penas no mínimo, atenuadas por menoridade relativa / por confissão / compensada reincidência por confissão, com máxima redução, em regime brando tomada detração, com substituição, sendo facultado recurso em liberdade.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A pretensão acusatória comporta integral acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito, que se configurou consumado, clara a tipicidade, não havendo dúvidas quanto à autoria, correta a classificação dada à conduta.

O réu, ouvido na fase policial, negou estar vendendo drogas no local, relatando que é apenas usuário de cocaína, e estava no local sentado em uma cadeira, do lado de fora de uma lanchonete, aguardando o lanche que havia pedido, e que somente não sentou no interior da lanchonete pois havia uma funcionária limpando o estabelecimento; portava apenas um maço de cigarro com um papelote de cocaína dentro, e negou estar segurando uma sacola nas mãos; quando abordado pelos policiais disse a eles que possuía apenas uma cocaína no maço de cigarro, e foi levado preso (fls. 10). Ouvido em Juízo, negou a prática do delito; tinha saído de sua casa e foi à lanchonete que existe logo em frente, pediu um lanche e pegou uma cadeira com a comerciante na qual sentou para ficar aguardando; ela estava ainda lavando a lanchonete, tinha acabado de abrir; chegaram policiais, ficou sentado como estava, e foi abordado; nada foi apreendido em sua posse; não tinha dinheiro consigo, nem para pagar o lanche, tinha conta na lanchonete; um policial ficou a seu lado, enquanto outro subiu por uma viela próxima; não tinha nenhuma sacola consigo e não viu a sacola ser apreendida; o fato ocorreu em dia útil por volta de 10h; ainda iria trabalhar, trabalhava em uma loja de salgados próxima ganhando R\$ 600,00 por mês; mora na rua onde foi preso desde a infância, com seus familiares; negou ser usuário de drogas; não conhecia os policiais anteriormente; negou antecedentes.

As negativas apresentadas pelo acusado, divergentes entre si as alegações formuladas à autoridade policial e as que foram dadas em Juízo, vêm isolada nos autos, confrontada pelo mais da prova colhida, a qual demonstra à saciedade a realidade da hipótese acusatória.

As circunstâncias da prisão do réu e da apreensão das drogas e do dinheiro foram descritas com clareza pelos policiais ouvidos, os quais, explicitando que não conheciam até então o acusado, apresentaram relatos detalhados e convincentes, coincidentes entre si e com o anteriormente informado à autoridade policial, acerca do ocorrido.

O policial militar João Daniel relatou em Juízo que estavam em patrulhamento, ao chegarem ao local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico de drogas, depararam-se com o réu, sentando em uma cadeira ao lado de uma lanchonete; ao avistar a equipe policial, o réu dispensou a sacola que tinha em suas mãos, jogando-a no chão ao seu lado; como havia um carro estacionado na frente do réu, este demorou a visualizar a equipe, assim já estavam próximos quando ele conseguiu avistá-los, abordaram-no e dentro da sacola por ele dispensada encontraram dinheiro e drogas; o

réu negou o tráfico e a propriedade da sacola, disse que estava no local apenas para comer um lanche, na revista pessoal nada foi encontrado; havia uma única sacola, quando o réu a jogou no chão, algumas notas de dinheiro caíram de dentro dela e ele as recolheu; estavam de motocicleta, não é possível entrar de carro na rua onde o réu foi abordado pois é muito estreita e sem saída, no final dela há uma escada que dá acesso a uma comunidade; a família do réu compareceu ao local após a abordagem e foi informada do ocorrido.

O policial militar Diogo descreveu em Juízo que estavam fazendo patrulhamento pelo local, conhecido como ponto de tráfico; quando entraram na via, havia carros estacionados, sendo que o réu estava sentado em uma cadeira avulsa logo atrás dos veículos; ao ver os policiais, o réu dispensou uma sacola preta que tinha com ele e se levantou; abordaram o réu, com quem nada foi encontrado em busca pessoal, e apreenderam a sacola, que continha porções de drogas e dinheiro; havia estabelecimentos na mesma rua, mas nenhum deles tinham cadeiras ou mesas, a cadeira que o réu usava estava ali avulsa mesmo; o réu estava consumindo bebida alcoólica, foi ficando alterado conforme foram encontrando as drogas; o réu mencionou que morava nas proximidades; não havia ninguém perto do réu no momento da abordagem; viu o gesto do réu de dispensar a sacola com as drogas; após a abordagem, aproximaram-se familiares do réu.

Ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que os policiais alterassem informes quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão, convindo notar que o réu não era conhecido anteriormente dos policiais e que estes não praticaram atividade ilegal qualquer que necessitasse ser justificada pela apresentação de narrativa falsa.

Não há nos autos indicação de qualquer motivo para que as testemunhas mentissem, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar o réu, que nem conheciam, assomando que imbuídas somente de interesse no esclarecimento da verdade.

Bem assentado, assim, que o réu foi surpreendido em ponto estabelecido de tráfico, tendo diretamente consigo uma sacola contendo as porções de drogas, estas separadas por espécie, e dinheiro, compreendendo-se que o réu, por estar sentado atrás de carros estacionados, não estava atento e não notou a aproximação da polícia, não tendo tido oportunidade de se furtar da abordagem, tendo tido a reação de se desfazer da sacola ainda à vista dos policiais.

O conjunto probatório é seguro e convincente, dado que é pelos relatos coincidentes das testemunhas, de tal sorte que materialidade e autoria do delito encontram-se perfeitamente comprovadas.

As drogas vêm descritas no auto de apreensão de fls. 14/15, estando a materialidade do delito demonstrada pelo auto de constatação de fls. 27/30 e pelo laudo químico toxicológico de fls. 148/150, em que apontada a presença dos princípios ativos característicos nas substâncias apreendidas.

A quantidade (197 porções), a variedade (maconha, cocaína e crack), o modo de disposição das drogas e as circunstâncias em que apreendidas, quando postado o réu em ponto estabelecido de tráfico, estando ali disposta inclusive uma cadeira que não era de nenhum estabelecimento próximo, não se mostram compatíveis com destinação outra que não o comércio ilícito, de que claramente proveniente o dinheiro apreendido.

A condenação do acusado é, pois, de rigor. Passo à dosagem das penas que lhe serão impostas.

Ao delito descrito pelo caput do artigo 33 da Lei 11.343/06 são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, as quais, consideradas exclusivamente para fixação da base, não se mostram de todo desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Atenuantes genéricas não incidem, dado não terem o condão de conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal, em observância ao princípio da legalidade (Súmula STJ 231).

RÉU PRIMÁRIO - FA a fls. 31/33 e certidão a fls. 34

Embora o réu seja reincidente, como comprova a certidão de fls. , uma vez que tal

circunstância atuará adiante para obstar a diminuição da pena na forma do parágrafo 4º ao artigo 33, não se presta a caracterizar a agravante genérica prevista pelo artigo 61, inciso I, do Código Penal, desde que assim não fosse ocorreria bis in idem.

Não atua, ademais, a agravante do artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, apontada na denúncia, reformulado, nesse ponto, o entendimento desde Juízo.

Com efeito, muito embora o crime realmente tenha sido praticado quando em vigor situação de calamidade assim reconhecida pelo poder público, decorrente da pandemia da doença provocada pelo corona vírus, não se observa que essa circunstância tenha sido algo relevante na prática do delito ou mesmo que da conduta tenha resultado algum efeito sobre a situação calamitosa.

Tratando-se, no caso, de circunstância meramente accidental, que não propiciou facilidade para a prática criminosa e nem tampouco foi impactada pela conduta do réu, não justifica o agravamento da punição.

Nesse sentido:

Ação Penal - Tráfico de Drogas - Sentença condenatória - Apreensão de maconha - Insurgência do réu - Pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 - Não cabimento - Circunstâncias da prisão e quantidade de entorpecentes apreendidos que afastam tal pretensão - Dicção do disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 - Dosimetria. Primeira fase - Pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes e da quantidade de entorpecente apreendido (quase 1 kg de maconha), na fração de 1/6 (05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa). Segunda fase - Atenuante de confissão espontânea compensada com a agravante de reincidência - Ainda na segunda fase, incidiu a agravante de calamidade pública em razão do Covid19, na fração de 1/6 - Respeitado o entendimento do nobre julgador, a agravante contida no art. 61, II, alínea "j", CP, não tem aplicação no caso - Inexistência de relação de causalidade entre a situação vivenciada no período de calamidade pública (Coronavírus) e a prática do tráfico de drogas - A exasperação da pena é devida quando o agente se aproveita de uma situação, para o cometimento do crime, o que não ocorre na espécie - Agravante afastada. Terceira fase - Redutor que não incidiu na espécie - Réu reincidente - Regime fechado que fica mantido - Recurso provido em parte para afastar a agravante de calamidade pública, redimensionando-se, assim, o quantum da reprimenda. Mantida, no mais, a r. sentença. (TJSP, 13ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Xisto Albarelli Rangel Neto, Apelação Criminal 1516263-33.2020.8.26.0228, deram parcial provimento, V.U., j. 25/3/2021).

No mesmo sentido: TJSP, 1ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Andrade Sampaio, Apelação Criminal 1512777-40.2020.8.26.0228, j. 25/3/2021; TJSP, 1ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Andrade Sampaio, Apelação Criminal 15'6422-

73.2020.8.26.0228, j. 25/3/2021; e TJSP, 10ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Francisco Bruno, Apelação Criminal 1517341-62.2020.8.26.0228, j. 25/3/2021.

A causa de diminuição prevista pelo parágrafo 4º incide em grau médio frente à primariedade do acusado, demonstrada pela FA de fls. 31/33, e à ausência de notícia de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Não houve, entretanto, demonstração de aptidão a vida regrada ou de dedicação a vínculo duradouro de trabalho, não tendo o réu comprovado registro de emprego ainda que pretérito em carteira de trabalho ou mesmo apresentado declaração de emprego, ausente prova positiva, que cabia à defesa, de bons antecedentes (os quais não se inferem da mera ausência de maus antecedentes). Vão as penas, pois, a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em definitivo, nada mais havendo a considerar.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime semiaberto, único que se mostra adequado à consecução das finalidades da sanção penal, mesmo à vista do quantum fixado, considerada a gravidade objetiva da conduta em exame - tráfico tendo por objeto, além de maconha, também cocaína e crack - que reclama reação severa, proporcional e seguramente eficaz. A conduta aqui apurada é daquelas que, em práticas reiteradas, vem comprometendo sensivelmente a qualidade de vida na cidade ao inculcar sensação de insegurança no meio social.

Cabe eleição do regime prisional mais gravoso mesmo quando, consideradas apenas

para efeito de fixação do montante da reprimenda, não se tenham mostrado desfavoráveis as circunstâncias judiciais, que, de resto, recomendam a segregação plena inicial.

Nesse ponto anoto que o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal cuida da determinação do regime inicial de cumprimento de pena, não tratando de hipótese de progressão, quando haveria consideração de requisito subjetivo atinente ao merecimento do condenado. Logo, alcança somente os casos em que a fixação do regime prisional se faça exclusivamente pelo quantum da pena, não sendo esse o caso dos autos. Nesse sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante (TJSP, 13ª Câ. Crim., Habeas Corpus nº 0190234-85.2013.8.26.000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 16/01/2014).

Dessa forma, cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução Penal, observado o regime inicial ora estabelecido.

Ausentes os requisitos legais, inviável a substituição da pena corporal. Apesar de suspensão vedação legal à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pela Resolução 5/2.012 do Senado Federal, a natureza do delito não se coaduna com a benesse pretendida, cuja aplicação redundaria em comprometimento da finalidade da sanção penal, em especial no tocante à função de prevenção geral, não se afigurando a medida socialmente recomendável (art. 44, inciso III, e § 3º, CP). À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu GERSON DA SILVA SANTOS, identificado a fls. 19/20 e qualificado a fls. 11, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, às penas de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Suspendo a execução da pena de reclusão pelo prazo de 2 (dois) anos, ao longo do qual obrigado o réu a comparecer mensalmente perante o Juízo de execução para informar e justificar suas atividades e proibido de mudar de endereço e de se ausentar da Comarca de residência sem prévia autorização judicial; no primeiro ano do período de prova, o réu está obrigado a prestar serviços à comunidade ou a entidades públicas, tal como dispuser o Juízo de execução.

As mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar do acusado no curso do feito permanecem presentes, vendo-se ainda reclamada a cautela uma vez que, determinada a imposição de pena ao acusado, patente o risco de que solto procure obstar a aplicação da lei penal pondo-se em fuga. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Autorizo que se proceda à destruição das drogas apreendidas. Oficie-se desde logo para tanto.

Após o trânsito em julgado a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para o pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) proceda-se à transferência do dinheiro apreendido a fls. 14/15 e depositado a fls. 68 ao Funad, decretado seu perdimento em favor da União; d) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, intimadas as partes. Comunique-se.

São Paulo, 01 de fevereiro de 2022.

VAI ESTE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, CONFORME É APONTADO EM SUA MARGEM SUPERIOR / DIREITA